



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Registro: 2018.0000089871

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0000386-76.2016.8.26.0355, da Comarca de Miracatu, em que é apelante ANTONIO CARLOS PINCELLI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 2ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso interposto por Antonio Carlos Pincelli para o fim de anular a condenação por infração à norma do artigo 345 do Código Penal, mantida a condenação e a respectiva pena quanto ao crime do artigo 129, parágrafo 9º do Código Penal. VU", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALEX ZILENOVSKI (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E KENARIK BOUJIKIAN.

São Paulo, 19 de fevereiro de 2018

SÉRGIO MAZINA MARTINS

RELATOR

Assinatura Eletrônica



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Apelação Criminal nº 0000386-76.2016.8.26.0355

2ª Vara da Comarca de Miracatu

Apelante: Antonio Carlos Pincelli

Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo

Voto nº 6651

Apelação criminal. Roubo. Exercício arbitrário das próprias razões. Correlação entre acusação e sentença condenatória. Há de ser mantida a estrita correlação entre a sentença e a denúncia, não podendo o réu ser julgado por fatos não contidos na acusação original, senão na forma e pela ferramenta solene do artigo 384 do Código de Processo Penal que, todavia, não tem como ser disposta tardiamente por iniciativa do tribunal, em sede de recurso.

Vistos.

Trata-se de apelação interposta pelo acusado **Antonio Carlos Pincelli** em face da sentença de primeira instância que, julgando-o infrator da norma do artigo 345, *caput*, c.c. o artigo 129, parágrafo 9º, ambos do Código Penal, aplicou-lhe a pena total e definitiva de três (3) meses e quinze (15) dias de detenção, a ser cumprida no regime prisional inicialmente aberto, e pagamento de dez (10) dias-multa, arbitrados no patamar legal mínimo.

Reclama o apelante a nulidade absoluta da sentença, que decidiu *extra petita*, condenando o réu por delito não descrito na denúncia, violando assim o princípio da correlação entre acusação e sentença.

O recurso foi devidamente recebido e processado, manifestando-se o Ministério Público pelo seu não provimento.

A Procuradoria Geral de Justiça, por sua vez, opinou pelo provimento do recurso, para anular a r. sentença condenatória,



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

oportunizando o aditamento à denúncia, nos termos do artigo 384 e parágrafos do Código de Processo Penal.

É o relatório.

Dá-se provimento parcial ao recurso interposto.

A existência material dos fatos está comprovada pelo termo de representação da vítima (fls.4), boletim e ocorrência (fls. 5-6), termo de ciência da Lei Maria da Penha (fls. 10), pedido de medida protetiva (fls. 11), documento (fls. 23), laudo pericial de lesões corporais (fls. 25), auto de avaliação (fls. 28), vindo confirmada em diversos momentos da prova oral produzida.

Perante a autoridade policial, Antonio relatou que estava se separando da vítima Katia, com quem viveu em união estável por dez anos. Afirmou que pretendia, também, retirar seus pertences pessoais que permaneciam no lar conjugal e, no dia dos fatos, encontraram-se na via pública quando iniciaram uma discussão. Sempre segundo o acusado, Katia recusou-se a devolver ao declarante seu telefone celular, que estava na posse dela. Diante da recusa da ex-companheira, o declarante segurou Katia com uma das mãos e, com a outra, retirou o celular que estava dentro da bolsa. Asseverou que Katia ficou bastante irritada e *partiu para cima* do declarante, arremessando-lhe uma pedra que acabou atingindo o vidro de seu caminhão que estava estacionado, quebrando-o. Ato contínuo, continuou Antonio, Katia tentou pegar outra pedra para agredi-lo, mas o declarante a conteve, segurando-a pelos braços e ombros, deixando o local em seguida, já em posse de seu aparelho de telefonia celular que era dele. Esclareceu não ter agredido a vítima, pois apenas a segurou para contê-la (fls. 19-20).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Já em Juízo, quando cercado das garantias, solenidades e cuidados do processo, Antonio confirmou a briga do casal e sua intenção em recuperar o telefone celular que lhe pertencia, mas estava em posse da ex-companheira. Negou tê-la agredido, argumentando que apenas usou de força física para contê-la quando Katia tentou arremessar uma pedra em sua direção. Ato contínuo, subiu em seu caminhão e partiu, na posse do referido celular que era de sua propriedade. Esclareceu que o celular lhe pertencia, inclusive era ele mesmo quem pagava a conta dos serviços telefônicos *pós paga*, embora Katia estivesse com o aparelho há um ano e meio. Admitiu ter cedido o celular para a companheira, mas negou que fosse um presente, acrescentando não ter sido o primeiro telefone que cedeu para ela (103-106).

A vítima Katia, por sua vez, tanto na polícia quanto me Juízo, afirmou que Antonio lhe presenteara no dia das mães com o referido celular, embora a nota fiscal e a conta estivessem mesmo registradas em nome dele. Em juízo, Katia acrescentou ter recebido um telefonema de Antonio, que parecia bastante grosseiro, questionando sobre sua vida pessoal, embora já estivessem separados há dois meses. Asseverou que o ex-companheiro disse que iria à sua casa fazer escândalo caso não o procurasse para conversarem. Chegando à casa do acusado, continuou Katia, ele passou a xingá-la de *vagabunda*, puxou sua bolsa e pegou o celular que estava dentro dessa bolsa e, depois, desferiu-lhe um tapa e um soco, deixando seu braço roxo, rasgou sua blusa e a ofendeu dizendo que havia dormido com um homem *de carro preto*. Admitiu ter arremessado uma pedra no parabrisa do caminhão de Antonio, que estava estacionado e



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

vazio. Após estes fatos, recebeu mensagens ameaçadoras de Antonio, dizendo que deveria *retirar a queixa* senão perderia o emprego e, desde então, ele não a pode ver, passa pela depoente esbarrando e já a *encurralou* no carro. Acrescentou que, embora o *chip* estivesse em nome de Antonio, todos os contatos eram dela e ele passou a enviar mensagens para os seus amigos, *marcou até encontros* em seu nome.

De início cumpre ressaltar que um mero olhar pela denúncia é suficiente para se verificar que o acusado foi efetivamente denunciado por roubo, descrevendo a denúncia não apenas a *subtração* do celular da ofendida, como também as agressões por ela sofridas, consistentes em *tapas, socos e puxões, causando arranhaduras no ombro direito e escoriações na mão esquerda*, devidamente comprovadas pelo respectivo laudo de lesão corporal (fls. 1-2).

Depois de instruído o feito, a nobre julgadora *a quo*, valorando as provas colacionadas aos autos, entendeu por bem desclassificar a conduta imputada. Reconheceu S. Exa. a ausência de uma das elementares do delito patrimonial imputado na denúncia, qual seja, o ânimo de assenhoramento de *coisa alheia*, asseverando na decisão ora atacada que a titularidade dominial do aparelho celular é, comprovadamente, do acusado, eis que o *chip* e a conta telefônica estão mesmo registrados em nome dele (cf. fls. 23), o que, inclusive, foi corroborado pela vítima em seu depoimento.

Acrescentou, ainda, a magistrada que, *no contexto da separação de um casal, restam dúvidas e conflitos acerca da titularidade de bens adquiridos no decorrer da união, sendo crível, portanto, que o réu pensasse que o celular lhe pertencia. Desse*



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

modo, não restou demonstrado o elemento subjetivo do crime de roubo, pois não há prova inequívoca de que o réu agiu com o intuito de subtrair 'coisa alheia'. Ao contrário, como exposto, as provas dos autos indicam que o autor agiu com dolo de recuperar um bem que, embora estivesse com a ofendida, ele julgava lhe pertencer. Nesse cenário, a conduta narrada na inicial melhor se amolda no artigo 345 do Código Penal, que tipifica o exercício arbitrário das próprias razões (fls. 122).

E para exercer esse exercício de forma plena, desferiu tapas e socos na vítima, nela provocando lesões corporais de natureza leve (fls. 24-25), conduta esta caracterizadora do crime de lesões corporais, aliás, devidamente descrito na denúncia.

Portanto, tal como bem examinado pela julgadora *a quo*, não há como se extrair elementos de convicção que atestem a intenção do réu em apossar-se de bens pertencentes à vítima.

No caso em tela, não há como admitir como verdadeira a tese da acusação, no sentido de que o réu tinha a inequívoca intenção de subtrair o celular da ofendida, mediante o emprego de violência. De fato, não se pode aferir, com a certeza exigível para um decreto condenatório, que o réu tinha a intenção de praticar o roubo.

Em memoriais, o Ministério Público manteve o seu posicionamento quanto ao delito patrimonial e não aditou a denúncia, pedindo a condenação de Antonio por infração do artigo 157, *caput* do Código Penal.

Tal como bem examinado da sentença, não há mesmo elementos de convicção suficientes a ensejar a procedência da denúncia prefacial quanto à imputação de roubo, já que não há



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

nenhuma evidência que ateste, sem sobra de dúvidas, o ânimo de assenhoramento definitivo do aparelho de telefone celular que fosse da vítima, pelo que as agressões físicas por ela sofridas se subsumem na figura típica do art. 129, parágrafo 9º, do Código Penal.

Não demonstrados que os bens subtraídos eram de propriedade da ofendida ou terceiros, mas, ao contrário, pertencia ao próprio acusado, era de rigor sua absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso II do Código de Processo Penal, remanescendo apenas a condenação pelo tipo do artigo 129, parágrafo 9º, este sim bem comprovado nos autos e desde o início inteiramente contido na descrição dos fatos da denúncia.

Ora, quanto a essa lesão corporal, a MMª Juíza de origem realmente poderia desclassificar o crime sem necessidade de aditamento da denúncia, mesmo porque o julgador, sabidamente, não está adstrito ao entendimento do órgão acusador.

Contudo, já para que se cogitasse do crime de exercício arbitrário das próprias razões, na órbita do artigo 345 do Código Penal, tem-se que os fatos articulados originalmente na denúncia tal não comportavam. Seria, por consequência, imprescindível o procedimento mais oneroso do artigo 384 do Código de Processo Penal que, todavia, aqui não foi seguido em primeira instância.

É que, nesse caso, o juiz não tem mais liberdade jurídica para desclassificar o crime sem aditamento da denúncia. Não tendo sido aplicado esse procedimento – repita-se: como aqui efetivamente não foi – em se tratando de ação penal pública, deverá o magistrado ao final curvar-se ao entendimento do órgão acusador formulado originalmente na denúncia – no caso, condenando o réu por roubo



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

quando certamente roubo não houve – ou absolvê-lo, caso entenda que a imputação inicial não restou provada.

Com a devida vênia, não cabe em segunda instância, por iniciativa do tribunal, a aplicação do artigo 384 do Código de Processo Penal, mecanismo que implicaria violação implícita ao duplo grau de jurisdição e que, portanto, somente se aplica na origem.

Assim, os fatos delineados em uma peça acusatória limitam o julgador em seu pronunciamento final que, por sua vez, deve circunscrever-se à narração fática feita pelo órgão acusador e sobre as quais o imputado exercitou o seu amplo direito de defesa. A consonância que a sentença deve guardar com o fato narrado é medida que impede a ocorrência de julgamentos *extra petita* ou *ultra petita*, a impedir qualquer desobediência ao sistema acusatório assumido pela atual Constituição Federal (art. 129, I), sendo de rigor, dessa forma, a anulação da condenação de Antonio pelo crime do artigo 345, *caput* do Código Penal, remanescendo apenas a imputação de infrator do artigo 129, parágrafo 9º do mesmo diploma legal.

Passa-se à análise da pena aplicável ao crime de lesão corporal, cuja descrição fática, repita-se, *ab initio* estava completa na denúncia, inclusive quanto à situação de violência doméstica.

Na primeira fase da dosimetria, a pena partiu do patamar mínimo e três (3) meses de detenção, que se tornou definitiva por ausentes outras causas modificativas na segunda e terceira fases do método trifásico.

Outrossim, fixado corretamente o regime aberto para o cumprimento inicial da pena.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Por outro lado, impende lembrar que se trata de crime cometido com violência contra a pessoa, sendo, portanto, defesa a substituição da pena privativa de liberdade por pena alternativa (inciso I, do artigo 44 do Código Penal e artigo 17 da Lei nº 11.340/2006).

Em face do exposto, **dá-se provimento parcial** ao recurso interposto por **Antonio Carlos Pincelli** para o fim de anular a condenação por infração à norma do artigo 345 do Código Penal, mantida a condenação e a respectiva pena quanto ao crime do artigo 129, parágrafo 9º do Código Penal.

Mazina Martins
Relator